



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צ. פיגנבוים

תיק מס': 225/03

בענין:

1. בויאנובסקי אלה
2. קגן רוזה
- ע"י ב"כ עוה"ד גלידר איגור ואח'
- רח' הנביאים 2, חיפה

התובעות

נ ג ד

1. עו"ד רפאל בס, כונס נכסים
שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי, בנין "ברוש" חיפה

2. "טפחות" בנק משכנתאות לישראל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד רפאל בס
שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי, בנין "ברוש" חיפה

3. "עמידר" החברה הלאומית לשיכון בישראל
ע"י ב"כ עוה"ד שלמה שינדלהיים ואח'
שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי, בנין "אורן", חיפה

הנתבעים

פ ס ק - ד י 1

1. התובעות בהליך זה הגישו תביעה למתן צו עשה שיחייב את הנתבעים ליטול חלק בביצוע ובמימון משותפים של תיקון ריצפת דירת התובעות המהווה תקרת דירת הנתבעים, אשר בחלקה קרסה אל תוך דירת הנתבעים ויתרתה נתונה בסכנת קריסה.
2. מלכתחילה הוגשה התביעה נגד נתבעים 2, 3. כתב ההגנה שהגישה נתבעת מס' 2, כמו גם סיכומי הטענות שהגישה, מערב טענות של בנק ממשכן עם טענות של כונס נכסים תוך שהיא מזהה עצמה הן ככונס נכסים והן כבנק ממשכן. ראיתי בעירוב טענות זה תשתית ראויה לצרף את כונס הנכסים כצד להליך מתוקף הסמכות המוקנית לי בתקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, סעיף 75(א) לחוק המקרקעין ותקנה 71 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום).
3. הבית הנדון נמצא ברחוב השומר 28, חיפה ומזוהה כחלקה 9 בגוש 10864. על פי צו רישום הבית המשותף כולל הבית 5 דירות, כולן רשומות בבעלות רשות הפיתוח שנכסיה מנוהלים על ידי נתבעת מס' 3.

4. בכתבי ההגנה טוען כל אחד מהצדדים לאמור:

(א) נתבעת מס' 3 אוחדת בדעה כי יש לדחות את התביעה כנגדה מאחר והדירות נשוא התביעה נמכרו על ידה מספר שנים עובר להגשת התביעה וכי לא נדרש כנגדה כל סעד אופרטיבי, ובכלל היא מהווה רק חברה משכנת. יוטעם כי שלא כנטען על ידה, לזכות התובעות כמו גם לזכות החייב שעל נכסיו מונה כונס נכסים, לא רשומה שום זכות קניינית.

(ב) הנתבע מספר 1 מתייחס הן להיותו נושה והן להיותו כונס נכסים. הואיל והמדובר בשתי ישויות משפטיות נפרדות אפריד אף אני בין טיעוניהן:

– הכונס טוען כי מונה ככונס נכסים לפי סעיף 54 לחוק ההוצאה לפועל וסמכויותיו מוגבלות לביצוע הליכים למימוש הנכס ומכירתו תחת פיקוח ראש ההוצאה לפועל. הוצאות שיפוט הדירה הן חובה החלה על החייב, חובה שאינה נכנסת לגדר הפעולות המצויות בסמכותו ו/או אחריותו של הכונס.

– הבנק טוען כי ביום 20.3.01 ניתן צו לימוש משכון שהוא נתן לבעלי הדירה, ועו"ד בס בא כוח הבנק מונה כונס נכסים בגין זכויות החייב בדירה הממוקמת מתחת לדירת התובעות. בכל הפעולות אשר אינן קשורות במישרין למימוש הנכס אין ידו של הזוכה, באמצעות כונס הנכסים (כך בכתב ההגנה) כיד החייב. השתתפות הבנק בהוצאות שיפוט הדירה יסכל למעשה את מטרת הכינוס שהיא הקטנת החוב במידת האפשר. הבנק ממשיך ופועל למכירת הנכס במצבו החוקי והפיזי הנוכחי במטרה להקטין את החוב במידת האפשר.

2. מאחר והצדדים לא היו חלוקים בשאלה העובדתית האם נפער חור בתקרת דירת הנתבעים/ריצפת דירת התובעות, אפשרתי להם לסכם טענותיהם בכתב בשאלה על מי מהצדדים לבצע ולשאת בהוצאות התיקון, וזאת לאחר שהתובעות הכירו בכך שמחצית הסכום חלה עליהן.

3. הללו חזרו על עיקרי הדברים שהעלו בכתבי בי-דין ובקצירת האומר:

(א) התובעות הפנו אותי לסעיף 58 לחוק המקרקעין ולסעיף 3(ב) לתקנון המצוי אשר מכוחם חלה חובה על הנתבעים לבצע התיקונים של קיר המפריד בין שתי הדירות, אשר הינו בבחינת רכוש המשותף לשתי הדירות, וכן לסעיף 54 לחוק ההוצאה לפועל הקובע: "כונס הנכסים יקח לרשותו את הנכס שנתמנה לו, ינהלו, ימכרו, יממשו ויעשה בו כפי שיורה ראש ההוצאה לפועל; וידו של כונס הנכסים בכל אלה כיד החייב".

(ב) הנתבעת 2 (הבנק) חזרה על עיקרי טענותיה בכתב ההגנה.

- (ג) הנתבע 1 מצידו ביקש להבהיר כי סעיף 54 לחוק ההוצאה לפועל לעיל מצמצם תפקידו של כונס הנכסים למכירת זכויות החייב בנכס במצבו הקיים, במחיר גבוה ככל שניתן וללא פגיעה נוספת בקניינו של הבנק, היינו ללא חיובו בהוצאות נוספות; קרי ביצוע התיקון. זאת ועוד, חובתו של כונס הנכסים היא לפעול בנאמנות לטובת הזוכה ולהקטין נזקיו ככל שאפשר באופן שהנתבעים לא יישאו בחובות נוספים של החייב. נשיאה בהוצאות תיקון הרצפה, אשר מבחינה חוקית מוטלת על החייב עצמו, תסכל את הליך הכינוס אשר לא זו בלבד שאינו פורע חוב לנתבע-הבנק אלא גם מגדיל אותו בשיעור עלויות השיפוצים.
- (ד) לטענת הבנק עמדה ועומדת לתובעות האפשרות לנקוט הליכים ישירות כנגד החייב, אלא שמטעמי נוחות בחרו לפנות ולתבוע דווקא את הנתבע.
5. התובעות בהליך זה הגישו תביעה למתן צו עשה שיחייב את הנתבעים ליטול חלק בביצוע משותף של תיקון תקרת דירת הנתבעים-ריצפת דירת התובעים אשר בחלקה קרסה אל תוך דירת הנתבעים ואשר חלקה האחר הינו בסכנת קריסה.
6. הבית הנדון נמצא ברחוב השומר 28, חיפה ומזוהה כחלקה 9 בגוש 10864. על פי כתב רישום הבית המשותף כולל הבית 5 דירות. דירת התובעות מצויה מעל דירת הנתבעים.
7. בכתב ההגנה טוענת נתבעת מס' 2 כי יש לדחות את התביעה כנגדה מאחר והדירות נשוא התביעה נמכרו על ידה מספר שנים עובר להגשת התביעה וכי לא נדרש כנגדה כל סעד אופרטיבי. הנתבע מספר 1 טוען כי אמנם רשום לטובתו משכון (ולא משכנתא כנטען בטעות בכתב ההגנה) על הדירה המצויה מתחת לדירת התובעות אך ביום 20.03.01 מונה ע"י ראש ההוצאה לפועל עו"ד בס ככונס נכסים לדירה וכונס הנכסים אינו רשאי במסגרת סמכויותיו לבצע השיפוץ האמור ולהתחייב בהוצאותיו שכן החובה החלה עליו הינה הקטנת נזקי החייב ולא חיוב הזוכה בהוצאות נוספות.
8. מאחר והצדדים לא היו חלוקים לגבי העובדה שנפער חור בתקרת דירת הנתבעים/ריצפת דירת התובעות, אפשרתי לצדדים לסכם טענותיהם בכתב בשאלת המחויבות שחלה על מי מהצדדים לבצע ולשאת בהוצאות התיקון, וזאת לאחר שהתובעות הכירו בכך שמחצית הסכום חלה עליהן.
9. הללו חזרו על עיקרי הדברים שהעלו בכתבי בי-דין ובקצירת העומר:
- (א) התובעות הפנו אותי לסעיף 58 לחוק המקרקעין ולסעיף 3(ב) לתקנון המצוי אשר מכוחם חלה חובה על הנתבעים לבצע התיקונים של קיר המפריד בין שתי הדירות, אשר הינו בבחינת רכוש המשותף לשתי הדירות ולסעיף 54 לחוק ההוצאה לפועל הקובע: "כונס הנכסים יקח לרשותו את הנכס שנתמנה לו, ינהלו, ימכרו, יממשו ויעשה בו כפי שיוורה ראש ההוצאה לפועל; וידו של כונס הנכסים בכל אלה כיד החייב".

(ב) נתבע מס' 1 נימק העדר חובתו לתקן את הטעון תיקון בדירה לגביה מונה לשמש כונס בכך שסעיף 54 לחוק ההוצאה לפועל מצמצם תפקידו של כונס הנכסים למכירת זכויות החייב בנכס במצבו הקיים, במחיר גבוה ככל שניתן וללא פגיעה נוספת בקניינו של הבנק, היינו ללא חיובו בהוצאות נוספות; קרי ביצוע השיפוע. עוד טען כי חובתו של כונס הנכסים היא לפעול בנאמנות לטובת הזוכה ולהקטין נזקיו ככל שאפשר באופן שהזוכה לא יישא בחובות נוספים של החייב. נשיאה בהוצאות תיקון הרצפה, אשר מבחינה חוקית מוטלת על החייב עצמו, תסכל את הליך הכינוס אשר לא זו בלבד שאינו פורע חוב לנתבע-הבנק אלא גם מגדיל אותו בשיעור עלויות השיפועים. חיוב הכונס משמעותה חיוב לפעול בניגוד לחובת הנאמנות שלו לבנק ואף לגרימת נזק כספי לבנק.

(ג) נתבעת מס' 2, עד כמה שניתן לדלות את נימוקיה מתוך כתב הסיכומים, טוענת כי התובעים מזהים את הבנק כ"כיס עמוק" ממנו אפשר לדלות כסף ולכן בחרו לזנוח הליכים אפשריים והכרחיים נגד החייב ולנקוט בהליכים נגד הבנק בלבד.

(ד) הנתבעת 3 חזרה על עיקרי טענותיה בכתב ההגנה.

10. יישום החוק והפסיקה הרלוונטיים על עובדות המקרה מחייב קבלת התביעה בשינויים כפי שיפורטו להלן ומתן הסעד המבוקש. אלה נימוקי החלטתי:

(א) בפסיקה ובספרות המשפטית קיימת מחלוקת כיצד לאפיין מחיצות המבדילות בין דירות: האם כקנין הנתון בבעלות משותפת של שני בעלי הדירות משני צדי המחיצה או בבעלות נפרדת של בעלי הדירות משני צידי המחיצה כך שלכל בעל דירה בעלות עד קו האמצע של המחיצה (ראה י. ויסמן בספרו דיני קניין-בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997 עמ' 385-390). מכל מקום אין מחלוקת כי עסקינן במחיצה כהגדרה לעיל. לפי שריצפת דירת התובעות נושא הדיון מהווה תקרת הדירה מתחתיה - זו הנמצאת בכינוס. ואולם, בין אם המחיצה בבעלות משותפת של בעלי הדירות משני צידיה, ובין אם בבעלות פרטית של בעלי הדירות הנ"ל עד לקו האמצע, התוצאה המשפטית בשני המצבים זהה.

(ב) סעיף 3(ב) לתקנון המצוי קובע כי "בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".

(ג) ביום 20.03.01 מונה נתבע מס' 1 לשמש כונס נכסים לדירה עליה קיים משכון לטובת הנתבע 2, עפ"י צו מינוי שצורף לכתב ההגנה מטעם נתבע 2. צו המינוי הסמיך את הכונס לפעול לתפיסת החזקה בנכס שבכינוס, מימושו ועוד מטלות כמפורט בצו המינוי. הנכס הוגדר בצו המינוי כדירה נושא התביעה. למיטב הבנתי חוק המקרקעין מזהה דירה כיחידה אחת שלמה; הפגם שנפל בה, הוא עילת התביעה, נוטל ממנה את אופייה כדירה.

(ד) מרגע שמונה כונס נכסים על הדירה מופקעת למעשה החזקה בדירה מידי בעליה ועוברת לידי כונס הנכסים שעושה למכירתה - העברת הבעלות בה, ומרגע זה הזכויות הנובעות מהדירה כמו גם החובות הרובצים עליה חלים על כונס הנכסים. בעל הדירה, אפילו חפץ בכך, לא יכול לבצע התיקונים מאחר שהחזקה בדירה ניטלה ממנו והכונס פועל אף להוצאת הבעלות ממנו. ראה מכתבו של הכונס לב"כ התובעות מיום 12.6.03 אשר צורף לתביעה, בו הוא מודיע כי כל פעולה שהתובעות תעשינה בנכס בטרם קבלת אישור כמתחייב מהיותו כונס נכסים, תהיינה השגת גבול בנכס שבכנוס.

(ה) מרגע שמונה כונס נכסים בעל הזכויות בדירה שבכינוס, הוא החייב לבנק שלנכסיו מונה כונס נכסים, הגם שאינו אחד מהנתבעים, אינו עוד צד ראוי לתביעת התובעות. שהרי מרגע שמונה כונס נכסים לדירתו וניטלה ממנו החזקה בדירה, ידו של כונס הנכסים הנה כידו של החייב, כך מורה אותו סעיף 54(א) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז-1967.

(ו) סעיף 54(א) לחוק ההוצאה לפועל מקנה לכונס הנכסים סמכות לנהל את הנכס למכרו ולממשו וידו בכל אלה כיד החייב. טול דוגמא בה כונס נכסים אוזז בדירה אשר הצנרת שבה התפוצצה וגורמת נזקי מים ורטיבות לדירה עצמה כמו גם לדירות אחרות בבית. היעלה על הדעת כי יוכל לסרב לתקן הנזקים בדירה האמורה בטענה שבכך הוא מגדיל חובות החייב ומסכל מטרת הכינוס? שהרי אותו התיקון אינו חוב של החייב אלא חלק מהוצאות הכינוס. הוא הדין לגבי תשלום ארנונה והיטלים אחריו שחלים על הכונס בתקופה בה שימש כונס, כולם תשלומים המהווים חלק מהוצאות הכינוס.

(ז) שלא כטענת הנתבעים 1, 2 גם יחד, כונס הנכסים לחלוטין אינו נאמן של הבנק שיזם את המינוי. ראה פסק דינו של ביהמ"ש בע"א 1034/92 רמות זכרון בע"מ (בכינוס נכסים) נ' ד"ר אליעזר וולף (לא פורסם): "כונס הנכסים שנתמנה ע"י בית המשפט פועל מטעם בית המשפט כעושה דברו (OFFICE OF THE COURT), ואינו סוכנו או שליחו של הנושה אשר הציעו וביקש את מינויו. על הכונס להניח דעתו של בית המשפט שפעל כדין ולטובת הכינוס". ובהמשך פסק הדין: "מוטלת עליו חובה אובייקטיבית במילוי תפקידו ואין הוא צריך לקדם את האינטרסים של הגורם מטעמו הוצע ככונס, שהרי אחרת תהיה בכך פגיעה באינטרסים של נכסי הכינוס או של נושים אחרים".

(ח) ועוד - "כונסים המתמנים ע"י בית המשפט הם פקידיו והם פועלים בשמו בהתאם לכתב הסמכות שניתן להם וכפופים למרותו. גם כונס שנתמנה לפי בקשת נושה מובטח איננו סוכנו של הנושה. כל רכוש הבא לידי הכונס הוא מחזיק בו לא בשם הנושה כי אם בשם בית המשפט, ובידי בית המשפט ההחלטה הסופית מה ייעשה בו. בעצם, הכונסים באים בנעלי החייב שעל כינוס נכסיו הם ממונים, אלא שתפקידי הכינוס והניהול (במידה שגם זה מוטל עליהם) הם למטרה מוגדרת. התפקיד הוא לממש את נכסי החייב ולסלק בתחילה את החוב המובטח ולאחר מכן את החובות האחרים, ומה שנשאר, אם נשאר, חוזר לחייב..." ראה ע"א 522/72, מ"י נ' כונסי הנכסים של וולטקס צמרון, פד"י כז (2) 393,398. וברע"א 2077/92 אדלסון נ' רייף

פד"י מז (3) 499,485 נאמר: "כונסי הנכסים הם פקידי בית המשפט ופועלים בשמו, חייבים הם אפוא במידת האובייקטיביות במילוי תפקידם, בנאמנות לבית המשפט בלבד ובציות להוראותיו. עם מינויים של כונסי הנכסים עוברים נכסי החייב לשליטת בית המשפט, וזה לא יסבול התערבות של מאן דהוא במעשים של עושי דברו אלא ידאג הוא בעצמו לכך שייעשה בנכסים מה שצריך להיעשות...".

(ט) מכוח סעיפים 39, 61(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 חייב כונס הנכסים לעשות שימוש בסמכויותיו החוקיות בדרך מקובלת ובתום לב. גם חובת תום הלב מחייבת כי כונס הנכסים מרגע שמונה לתפקידו יהא אחראי על הנכס על כל המשתמע מכך. אחריותו של כונס הנכסים כלפי הנכס אינה מסתכמת בהפקת רווחים ממנו עם מכירתו, אלא היא נפרשת גם על חובות לשמירה על הנכס ולנזקים שנגרמו אם נגרמו בעטיו, עת היה הנכס באחריותו כמו גם חובות הנגזרות מעצם החזקה בנכס כגון ארנונה. כל עוד לא השתחרר הכונס מתפקידו, באופן שחזר הנכס לחזקת בעליו משתרעת אחריותו לנכס גם על מקרים כגון דא. התובעות גרות כיום בדירה שנפערה רצפתה ומלבד הסכנה המוחשית בה הן מצויות הן חשופות לפריצות המתרחשות חדשות לבקרים מתוך דירת הנתבעים. התובעות לבדן אינן יכולות לבצע התיקון שכן נדרש ביצוע התיקון גם מתוך הדירה שבכינוס וזו נמצאת בחזקת כונס הנכסים. הותרת מצב דירות התובעות והנתבעים במצבן גם הוא אינו אפשרי.

(י) כאמור לעיל הוצאות התיקון אינן בבחינת השבחת הנכס אלא מהוות חלק מהוצאות הכינוס וככאלו נועדו לשרת ולאפשר מכירתה של הדירה כדירה. חובות והוצאות שנוצרו במהלך הכינוס ולצורך הכינוס הינן בדרגת עדיפות עליונה לפני כל חוב אחר ואף לפני חובות בדין קדימה (ראה כינוס נכסים הלכה ומעשה מאת עו"ד גפני ונרקיס בעמ' 331) וכהיקש ראה גם סעיף 77 לפקודת פשיטת רגל, תש"ס-1980, והדברים ידועים.

(יא) מענה לעמדת הבנק כאילו תיקון הדירה רק מגדיל את הוצאותיו ומהווה ניגוד אינטרסים להליכי הכינוס נמצא בדברי ביהמ"ש בת"א (ת"א) 2050/87, המ' 7223/91, יריב חברה למסחר והשקעות בע"מ נ' עירית חיפה ואח' (לא פורסם) שם נאמר כי די שההוצאה נעשתה כדי לקדם אינטרס של הנושה המובטח, לרבות אינטרס המשותף לו ולנושים אחרים, כדי שבית המשפט יקבע שההוצאה נעשתה לתועלתו של הנושה המובטח.

17. אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעים 1 ו-2, יחד ולחוד, לאפשר ולא למנוע בעד הנתבעות או מי מטעמן כניסה לדירת הנתבעים כמספר הפעמים הנחוץ לשם תיקון החור שנפער בתקרת הדירה. חיוב זה יכנס לתוקפו אם הנתבעים הללו לא יפקידו בידי התובעות מפתח לדירתם או יגיעו עמן להסדר מוסכם אחר בתוך 10 ימים מיום שיקבלו את פסק הדין.

12. בנוסף אני מחייבת את הנתבעות 1 ו-2, יחד ולחוד, לשאת במחצית ההוצאה בה תישאנה התובעות לתיקון התקרה/ריצפה על חשבונית מס שיגישו התובעות לנתבעים 1 ו-2 או מי מהם תוך 30 יום מיום הצגת החשבונית. במידה שיוותרו חילוקי דעות בקשר לסכום אזי אשלים את פסק הדין על פי בקשה שתוגש לי על ידי צד מעוניין.
13. מצאתי כי נכון להורות על צירוף נתבעת מס' 3 כצד להליך בתוקף היותה הבעלים הרשום בפנקס המקרקעין. מאחר ולא נדרש סעד ממנה לא אחייב אותה אף אני אם כי נכון היה שתהיה צד להליך.
14. אינני עושה צו להוצאות.
15. לנוכח האפשרות, הגם שלא הוכחה לי ואינני עושה מימצא בנדון, להשפעת החור הנדון על יציבות המבנה, אני מורה למזכירות הלשכה לשלוח עותק מפסק הדין למחלקה למבנים מסוכנים בעיריית חיפה.

ניתן בהעדר הצדדים ביום א' ג' בטבת תשס"ד (28.12.03)
העתקים ישלחו לצדדים.

צ. פיגנבויס
מפקחת על רישום מקרקעין